

1501422-38.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... policiais. Já foi preso pela prática de tráfico e liberado em audiência de custódia. Estava desempregado na época dos fatos e não conhecia os policiais que o abordaram.

E a confissão parcial do acusado foi corroborada pela prova oral produzida em juízo, a qual demonstra que toda a droga apreendida realmente pertencia a ele e se destinava ao tráfico.

Com efeito, ouvido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501422-38.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501422-38.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO NASCIMENTO DIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

Vistos.

LEANDRO NASCIMENTO DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 23:29 horas, na Rua Joseph Smith Junior, 663, Bairro São José, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 56,81 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 5 pedras de crack e 62 microtubos de cocaína), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de

causar dependência física e/ou psíquica.

O réu foi notificado (fls. 91) e apresentou defesa preliminar a fls. 110/115. A denúncia foi recebida a fls. 121/123. No decorrer da instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e, após, interrogado o acusado (fls. 149/155).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia (oralmente a fls. 152/155), ao passo que o Dr. Defensor, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante genérica da confissão, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas na fração máxima, a imposição de regime inicial aberto e a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 152/155).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudos de constatação prévia de fls. 14/15 e exames químicos toxicológicos encartados a fls. 68/70 e 71/73, que resultaram positivos para cocaína.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do tráfico. Disse que realmente estava no bar com cinco pedras de crack para venda. Havia acabado de chegar ao bar e ainda não tinha vendido nenhuma porção de crack. O dinheiro apreendido em seu poder obteve fazendo bico como servente de pedreiro. Não estava com pinos de cocaína. Não viu pinos de cocaína sendo encontrados no local pelos policiais. Já foi preso pela prática de tráfico e liberado em audiência de custódia. Estava desempregado na época dos fatos e não conhecia os policiais que o abordaram.

E a confissão parcial do acusado foi corroborada pela prova oral produzida em juízo, a qual demonstra que toda a droga apreendida realmente pertencia a ele e se destinava ao tráfico.

Com efeito, ouvido em Juízo, o policial Fernando disse que já possuíam informações de que o réu traficava no bar localizado no endereço descrito na denúncia. No dia dos fatos, passaram em frente ao bar e percebeu que o réu, que estava sentado, ao avistar a viatura, se levantou rapidamente, razão pela qual o abordaram. Em revista pessoal, localizou 05 pedras de crack na lateral do boné que o réu usava e, em suas vestes, cinco pinos com cocaína e R\$ 50,00 em dinheiro. Indagado, o réu confessou que estava traficando porque sua esposa estava grávida. Por ser um local conhecido como ponto de tráfico, fizeram vistoria nas imediações e um policial localizou no chão, sob umas folhas, um kit com 57 pinos de cocaína, da mesma cor dos cinco encontrados com o réu. O kit foi encontrado a cerca de 4 metros do local onde o réu foi abordado. O réu admitiu que toda a droga lhe pertencia e disse que vendia cada pino por R\$ 10,00. Já havia abordado o réu anteriormente, mas nada de ilícito foi encontrado em poder dele na ocasião.

No mesmo sentido são as declarações do policial Cleber, ouvido apenas na fase administrativa.

E não há porque se colocar em dúvida a versão do policial, porque como qualquer outra testemunha ele presta compromisso de dizer a verdade, e não viria a Juízo apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizou. Note-se que não há prova nos autos de qualquer desavença anterior entre os policiais e o

réu, de forma que seus depoimentos merecem credibilidade, pois não teriam qualquer motivo para acusarem injustamente um inocente. Enfim, não se pode desconsiderar uma prova por mera presunção, sem prova de suspeita ou má fé.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Por sua vez, o art. 207 estabelece quais as pessoas proibidas de depor, o que se dá em razão de função, ministério, ofício ou profissão, não estabelecendo qualquer restrição aos agentes que efetuem a prisão em flagrante no sentido de servirem como testemunhas. Assim, desde que tais depoimentos não se tornem suspeitos ou indignos de fé, têm plena validade em face da lei (TJSP - AC- Rel. Hoepfner Dutra - RT 416/96).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/2756).

Assim, o conjunto probatório é farto na demonstração de que toda a droga apreendida (as porções de crack e os pinos com cocaína) realmente pertencia ao acusado.

E o destino do entorpecente apreendido em poder do réu é manifesto, vez que trazia consigo e tinha em depósito, em um local conhecido como ponto de venda de drogas, uma considerável quantidade de drogas, ou seja, 56,81 gramas de cocaína. A quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida (cinco pedras de crack e sessenta e dois pinos com cocaína, prontos para imediata comercialização) já seriam suficientes para demonstrar a finalidade do tráfico de entorpecentes. Mas não é só. Em poder do réu, juntamente com parte da droga, foi encontrada a quantia de R\$ 50,00 em dinheiro sem comprovação de origem lícita, ou seja, o produto do crime. Diante dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes é evidente, mesmo porque admitido pelo réu em Juízo.

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, ante estarem demonstradas, in casu, de forma indubitável, a autoria e materialidade delitiva, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, em face da sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

O réu não ostenta antecedentes criminais. Analisando, ainda, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea porque a pena base já foi fixada em seu patamar mínimo legal e no direito brasileiro “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase de dosimetria penal, o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque, embora tecnicamente primário, o acusado praticou o crime objeto destes autos enquanto se encontrava em gozo de liberdade provisória (aproximadamente um mês após ser liberado), concedida no processo nº 1501303-77.2021.8.26.0603, pelo qual também responde pela prática de crime de tráfico de drogas (fls. 37). Tal circunstância, aliada ao fato de que o

acusado não possui emprego lícito comprovado nos autos e à quantidade e variedade de drogas encontrada, permite concluir que ele não se trata de mero traficante ocasional, mas sim que se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico seu meio de vida e fonte de renda. Assim, o réu não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício ---“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa---. Neste sentido: “1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Parcial provimento do recurso defensivo, para afastar a agravante relativa ao contexto de calamidade pública, mas sem reflexo no montante das penas. 2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Confissão judicial corroborada pelas demais provas. Delitos que podem ser atribuídos ao apelante. 3-) Dosimetria redimensionada, mas sem reflexo no “quantum”. Na primeira fase, a pena-base de cada delito foi fixada no mínimo legal, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa (tráfico) e três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa (porte ilegal de arma). Na segunda fase, embora não se discuta que os crimes ocorreram durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a sua realização, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, inc. II, “j”, do Código Penal não deve ser considerada. No mais, a presença da atenuante (confissão) não pode conduzir a pena aquém do mínimo estabelecido pelo legislador (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição no que tange ao delito do Estatuto do Desarmamento. Quanto ao tráfico, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode incidir. O apelante é jovem e primário, no entanto, havia quantidade considerável de droga e responde a outro processo por tráfico, estando em liberdade provisória quando cometeu os delitos ora em análise, o que mostra sua tendência delitiva, dedicação à ação criminosa. Pena final, pelo concurso material de delitos: oito (8) anos de reclusão e quinhentos e dez (510) dias-multa, retificando-se erro material. Não se exclui a sanção pecuniária, por falta de amparo legal. Observância do sistema trifásico. 4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela gravidade concreta dos delitos e personalidade voltada para a prática delitiva, com isso busca-se sua recuperação, prevenção criminal e reinserção na sociedade. 5-) Incabível a substituição das penas corporais por restritivas de direitos. 6-) Manutenção da prisão do recorrente”. (TJSP; Apelação Criminal 0000181-58.2021.8.26.0618; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021). “Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar – O indeferimento do pedido de realização de exame de dependência toxicológica não configura cerceamento de defesa – Ausência de elementos que indicassem qualquer comprometimento da capacidade cognitiva – Preliminar rejeitada – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Justiça Gratuita – Questão a ser apreciada pelo Juízo da Execução – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido. Apelação da Justiça Pública – Exasperação da pena-base – A despeito da natureza da droga apreendida, a quantidade de entorpecente não justifica a elevação da pena, com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas – Afastamento da causa de diminuição de pena prevista o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Acusado que responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime e voltou a delinquir após a concessão da liberdade provisória – Recurso de apelação parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1500140-96.2020.8.26.0603; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Criminal; Data

do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021). "1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito. Recurso defensivo não provido. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento do pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. Negativa de autoria infirmada pelos insuspeitos depoimentos de policiais militares. 3-) A dosimetria está correta. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo, isto é, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode incidir. O apelante é jovem e tecnicamente primário, no entanto, estava com quantidade razoável de droga, 55 unidades de cocaína e "maconha", além de responder a outro processo por delito de mesma natureza, estando em liberdade provisória apenas há três meses, o que mostra sua tendência delitiva, dedicação à ação criminosa. Pena final: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no patamar mínimo. 4-) Não se substitui a pena, pois ausentes os seus pressupostos. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas circunstâncias, pela gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Custódia cautelar mantida. A prisão é necessária, pois existe condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal." (TJSP; Apelação Criminal 1501204-44.2020.8.26.0603; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021 --- destaquei). Ausentes outras circunstâncias modificadoras de reprimenda, torno definitiva a pena aplicada, calculada a de multa no patamar mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LEANDRO NASCIMENTO DIAS, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O regime para o cumprimento de pena é o inicial fechado, justificável diante da latente e concreta gravidade do crime (o réu se dedica ao tráfico de cocaína, não se tratando o crime em questão do chamado "tráfico privilegiado", como já visto), fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando evidentemente prejudicada a aplicação da Lei nº 9.714/98, mesmo porque os objetivos do legislador com a promulgação desta Lei demonstram que ela afeta apenas aos crimes menos graves, distanciam-se em muito da hedionda mercancia.

Demais disso, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem favoráveis ao réu (o que não é o caso, por ser a pena superior a quatro anos de reclusão), não estaria configurado o previsto pelo inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso concreto, a insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes é patente, por conseguinte.

Considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto, e mormente o fato de ter sido preso em flagrante delito e encontrando-se detido até hoje, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o "fumus boni iuris", preso, após a prolação de sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade" (RJDTACRIM 13/181). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e nas que a mantiveram.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido” (TJSP; Apelação Criminal 1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Por fim, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os valores descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pois se tratam de produto do crime.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Araçatuba, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA